

1500724-04.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500724-04.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500724-04.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 23977964 - 02º D.P. AMERICANA, 638/22/345 - 02º D.P. AMERICANA, 2088010/2022 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN DA SILVA RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

JEAN DA SILVA RODRIGUES está sendo processado como incurso nas sanções dos artigos 33, 'caput', da Lei 11.343/06, acusado de no dia 30 de março de 2022, por volta de 16h06, na Avenida Bandeirantes, linha férrea, nesta cidade, trazer com ele, para fins de tráfico, dez kits contendo duzentos e oitenta e três (283) invólucros plásticos fechados por nó encerrando porção de material sólido petrificado com massa líquida de 49,1 gramas, na qual foi constatada a presença da substância "cocaína", embaladas separadamente, prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros, substâncias essas que provocam dependência física e psíquica, assim o

fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Recebida a denúncia em 12 de maio de 2022, fls. 104/105, o réu foi citado (fls. 122).

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa (fls. 93/94) e a acusação (fls. 103).

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação pugnou pela procedência da denúncia, provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 131/135).

A Defesa requer a absolvição por falta de provas. O acusado alegou que não estaria com drogas, fato admitido pelos guardas (estaria em uma moita). A acusação seria indevida e o réu já fora abordado em outras ocasiões. Reclama ausente testemunha que não fosse policial. Cita doutrina e jurisprudência. Invoca o 'in dubio pro reo'. Alternativamente, para o caso de condenação, pena mínima, com reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo, pela primariedade. A quantidade de drogas era inexpressiva. Faria jus à substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Regime brando, detração da pena e recurso em liberdade (fls. 138/145).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Na fase policial, Jean preservou silêncio (fls. 05).

"Na real verdade, preso naquelas circunstâncias a que a tradição do direito chama 'certeza visual do crime' (cf. Tostes Malta, Do flagrante delito, 1933, p. 25), e permanecendo calado na Polícia (fl.7), em vez de repelir, com a última força, a imputação, como fazem os inocentes, apenas o decreto condenatório poderia atender a um tempo à prova dos autos, à razão lógica e aos ditames da Justiça. Cai a lanço aquilo de Peter Thorton: 'A inocência pelo direito de falar; a culpa, essa invoca o privilégio do silêncio' (Justice on trial, p. 36; Revista da Escola Paulista da Magistratura, 2, p. 117). Impossível dizer melhor!" (TACRIM SP, 15ª C. - AP 1.286.483/3 - Rel. Carlos Biasotti, j. 07.02.2002, rolo-flash 1472/110).

"Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência não reservar-se para prestar esclarecimentos apenas em Juízo." (Ap. Crim. 1070141/5, Taubaté, Rel. Renato Nalini, TACRIM SP, j. em 20.10.1997).

"PROVA. Interrogatório policial. Silêncio do réu. Valor. O silêncio do réu, quando interrogado na fase policial, direito constitucional que lhe foi assegurado, é comprometedor, pois o inocente brada desde logo sua inocência e apresenta eventual alibi ou justificativa de seu ato." (TACRIM SP, AC 1.288.149/1, SP, 8ª Câmara, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 13.12.2001).

Já no interrogatório judicial, alegou que retornava da casa de uma amiga, ela não era a sua tia. Sua amiga lavava as suas roupas e guardava os seus documentos, se conheceram enquanto pegava marmitta. Era morador de rua, tinha um barraquinho na linha férrea. Foi abordado quando pegava dois galões de água. Apenas se agachou quando foi abordado, para colocar os dois galões na linha férrea. Negou ter se abaixado no capim para esconder drogas. Os entorpecentes não lhe pertenciam, não usava drogas. Dormia no barraco ou no terminal. Estava desempregado. Recebia benefício do Governo, bolsa família. Os guardas já o abordaram anteriormente, eles fiscalizavam para deixarem sujeiras no terminal desativado.

A versão não convence.

O guarda municipal Alan Fernandes esclareceu que a equipe patrulhava pela área central, quando avistaram o Jean. Ele estava no terminal, ao lado do Mercado Municipal. Ao notar a presença da viatura, o acusado demonstrou nervosismo e saiu andando. Na lateral do terminal, havia uma viela, com um muro baixo, que dava acesso à linha férrea. O suspeito correu e percorreu aquele caminho. A equipe desconfiou do Jean, decidiram pela abordagem. Desembarcaram pelo terminal e acompanharam o caminho percorrido pelo réu. No momento em que acessaria a viela,

observou que Jean estava com um objeto nas mãos. Enquanto percorria a linha férrea, Jean abaixou perto de uma moita de capim, colocou esse objeto e saiu andando, sentido à Avenida Abdo Najar. Fizeram a abordagem. Jean distava 30 metros da moita de capim, aproximadamente. Durante a revista pessoal, localizaram somente um celular da marca Motorola. Questionado sobre o que ele havia escondido no capim, o suspeito simplesmente olhou para a equipe e falou que nada era dele. Desta forma, a equipe diligenciou com a cadela Hana até a moita de Capim, que fez o trabalho de faro naquele local.

Na oportunidade, localizaram 283 pedras de crack, escondidas debaixo da moita. A planta estava morta, foi levantada e os entorpecentes foram colocados embaixo. Com essa droga em mãos, a equipe retornou até Jean e o questionaram novamente. Jean afirmou que as drogas não eram dele, que retornava da casa da tia que lavava as roupas dele. Durante os procedimentos na linha férrea, foi abordado um outro suspeito, que era procurado. Deslocaram até a residência da tia de Jean, que autorizou que averiguassem o imóvel. Na casa, localizaram um short, com uma carteira dentro, que continha o RG de Jean e a quantia de R\$ 700,00. Ao ser questionado sobre o dinheiro, ele falou que não lhe pertencia. Os fatos foram apresentados na Delegacia. A outra parte que foi abordada estava com um mandado de prisão em aberto, mas ele não estava junto com Jean. Durante o procedimento de faro, observaram que ele estava mais distante, em um local frequentado por usuários de drogas, por esse motivo realizaram a abordagem. O acusado estava sozinho, já o conhecia de abordagens anteriores, ele sempre ficava no mesmo ponto. Ele não tinha passagens policiais porque não localizaram drogas em seu poder nas abordagens anteriores.

Marcos César Ferreira, outro guarda, ratificando a versão do colega, lembrou-se de que patrulhavam pela rua Anhanguera. Quando acessaram o terminal metropolitano, avistaram Jean. Ao ver a viatura, o suspeito saiu andando de forma bem rápida e acessou uma viela, entre a Caixa Econômica Federal e o terminal metropolitano, que dá acesso a uma ferrovia. O GCM Fernandes desembarcou da viatura e correu atrás do suspeito, que estava agachado junto a uma moita. Após, Jean se levantou da moita e andou rápido, foi abordado um pouco mais adiante. Deu a volta com a viatura e realizaram procedimento de faro. Na moita em que Jean estava agachado, o animal localizou em torno de 10 kits, totalizando 283 pedras de crack. Indagado, Jean alegou que nada pertencia a ele. Detalhou que estava vindo da casa de uma tia, Noêmia, pela rua Dom Pedro. Foram até o local indicado pelo réu e contataram Noêmia, que franqueou a entrada da equipe e mostrou os pertences do Jean.

Nos pertences do acusado, estava a carteira dele, com vários documentos, além do valor de R\$ 700,00, que ele alegou não lhe pertencer. Diante dos fatos, Jean foi conduzido até a Delegacia, onde a autoridade policial deliberou pela prisão. Já abordou o acusado anteriormente, embaixo do viaduto Amadeu Elias, local conhecido como ponto de tráfico de drogas.

A prova, pois, é segura e convincente quanto a responsabilidade criminal do acusado.

O réu, não desconhecido dos guardas civis, foi visto em ponto de tráfico e em atitude suspeita. Demonstrou nervosismo, tentaram o abordar e ele saiu rapidamente. Acabou abordado junto à moita, onde foram dispensadas as drogas, 283 porções de cocaína, com massa de 49,1 gramas.

Os guardas, a respeito, deram versão coesa, convincente, inexistindo comprovação alguma de que o réu não tivesse vínculo com a droga, achada próxima a ele, após dispensa avistada pelos agentes.

Bem certa, a prova, assim, quanto a efetiva ocorrência do tráfico. As circunstâncias da prisão em local já conhecido como ponto de tráfico; a apreensão das drogas, já embaladas em pequenas porções, prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros; suspeita levada de dinheiro, sem procedência lícita provada, evidenciam que ele vinha se dedicando a essa atividade criminosa.

A quantidade e disposição, não permite inferir conclusão outra senão a de que se destinassem ao tráfico.

A alegação de que não tinha qualquer envolvimento com os entorpecentes não foi provada e muito menos é crível, pela citada forma em que fora surpreendido, quando

tentava se desfazer da droga, que estavam embaladas separadamente, a par da quantidade, local onde o réu se mantinha, crescendo-se o dinheiro localizado posteriormente.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o álibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

Também:

"Quem invoca um álibi, para ser absolvido, carece de cumpridamente demonstrá-lo, não bastando, para tal fim, produção de elementos de convicção que não excluam de vez a possibilidade de ter sido o autor da infração" (TJSP, AP. 53.726, Rel. Azevedo Franceschini).

A conduta é mesmo a de tráfico, não sendo necessário, para a hipótese, que o réu estivesse vendendo drogas. A acusação é pontual em alegar que trazia com ele drogas, para a mercancia.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

Também o fato de eventualmente ser usuário de drogas, não afasta a traficância, quando o porte de eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico.

A versão dos guardas municipais, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

É do C. STF: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros

elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por evidente, o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, crime de perigo abstrato e em que é irrelevante a quantidade da substância apreendida (neste sentido, 5ª T. STJ, Rel. Min. Jorge Mussi, REsp 1.637.113)

A materialidade da infração, no tráfico, foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo laudo de constatação (fls. 11/13), bem como pelo exame químico toxicológico (fls. 54/56).

Bem típica a conduta, pois, que merece severa punição.

Fixação das penas.

O réu é primário. Fixo a pena base no mínimo legal, não expressiva a quantidade de drogas para exasperação com fulcro no artigo 42 da Lei de Drogas.

Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas. Mantenho inalterada a pena base.

Na terceira fase, pela primariedade e não comprovação de que integrasse associação ou organização criminosa, possível a redução de pena no percentual de metade, o que se faz em atenção à quantidade-nocividade de droga apreendida.

É de se impor o regime inicial aberto, pela somatória da pena, reclusiva, sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em decorrência da primariedade e as circunstâncias judiciais já destacadas.

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que: "Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto." HC nº 239.999/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.

Na mesma evolução, com a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como "pacote anticrime"), houve necessidade de maior reflexão pelos julgadores.

Dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao "tráfico privilegiado": Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar JEAN DA SILVA RODRIGUES às penas de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, regime inicial aberto e duzentos e cinquenta (250) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput' e par. 4º, ambos da Lei número 11.343/2006.

Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena e mais dez (10) dias-multa, piso.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 34).

Vinculado o numerário apreendido e objetos com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Expeça-se alvará de soltura, pela substituição aqui operada.

P.I.C.

Americana, 27 de julho de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA